

1501157-41.2021.8.26.0666

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Artur Nogueira

Foro: Foro de Artur Nogueira

Vara: 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... dúvida alguma, então, a respeito da prática do tráfico de entorpecentes, com a incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, pois demonstrado que o acusado envolveu adolescentes para cometimento do crime, uma vez que ambos os guardas relataram que os infantes confirmaram o auxílio ao acusado na prática do tráfico.

Entretanto, considerando a especialidade dessa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Artur Nogueira

Foro de Artur Nogueira

Vara Única

Rua 13 de Maio, 140, Artur Nogueira-SP - cep 13160-170

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença 1501157-41.2021.8.26.0666 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501157-41.2021.8.26.0666

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2327118/2021 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 21717579 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 2774/21/309 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 2327118 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDRÉ KAYKY RIBEIRO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz Substituto: FELIPE CAVASSO

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra ANDRÉ KAYKY RIBEIRO DA SILVA como incurso nos artigos 33, caput, c.c artigo 40, inciso VI e artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 244-B, do ECA, porque em 01 de dezembro de 2021, por volta das 15h05min, na Rua Álvaro de Oliveira, nº 228, Vista Alegre e Rua Amália Vicensotti, nº83, Jardim Sacilotto, nesta cidade de Artur Nogueira-SP, o acusado, em concurso com os adolescentes JOÃO VITOR DOMINGUES e MICAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, trazia consigo e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 291 porções de Cocaína na forma de "Crack", totalizado 28,9 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de

fls. 23/24, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 25 e laudo toxicológico de fls. 151/153; consta também, do incluso inquérito policial, que em data incerta, mas anterior a 1 de dezembro de 2021, o acusado se associou aos adolescentes João Vitor Domingues e Micael Henrique De Oliveira com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes; consta também que o acusado, nas mesmas circunstâncias, corrompeu e facilitou a corrupção dos adolescentes já mencionados.

O réu foi notificado e apresentou resposta à acusação. Recebida a denúncia, designou-se audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, a desclassificação ou aplicação da pena em seu patamar mínimo, reconhecendo-se o tráfico privilegiado, com os consectários legais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Procede em parte a pretensão punitiva.

A materialidade está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 142/144), além dos demais elementos colhidos na fase policial, e sobretudo pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria é certa, até porque o acusado confessou a prática do tráfico de entorpecentes, afirmando que havia se mudado há pouco tempo para esta cidade e estava passando por necessidades.

De outro lado, os guardas municipais ouvidos em audiência, de forma uníssona, narram estar em patrulhamento preventivo pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de entorpecentes. Avistaram o réu, que estava em atitude suspeita e foi abordado. Com ele, localizaram 8 porções de pedras de crack e R\$ 31,00 em dinheiro e um aparelho celular. Indagado, ele confessou que estava naquele local vendendo drogas, por R\$ 10,00 cada, pois estava com filho pequeno, e estava com situação financeira difícil. Perguntado sobre se na sua residência havia mais drogas, alegou que tinha mais algumas porções pequenas de crack e indicou o local onde residia com o seu irmão adolescente e um amigo, mas não sabia o nome da rua, tendo conduzido os guardas até o local e autorizado a entrada no imóvel. Que ao chegarem na Rua Amalia Vicensotti, n. 83 no Jardim Sacilotto 2, verificaram que era um imóvel e duas casas na frente e no fundo e um corredor que dava acesso a ambas casas. Adentraram o corredor que teria sido apontado por André e como a residência do fundo como sendo a que estava morando e ali identificaram dois adolescentes no interior do imóvel, sendo eles Micael Henrique de Oliveira e João Vitor Domingues, os quais foram encontrados deitados em colchões no chão. Os adolescentes foram abordados, bem como revistado o imóvel, sendo encontrado, no bolso de uma blusa existente ali, 10 quites de pedras de crack totalizando 283 unidades e dezenas de embalagens plásticas, três aparelhos celulares e R\$ 19,00 em dinheiro. Que perguntado aos Adolescentes Micael e João, eles informaram que as drogas que estavam ali pertenciam a eles e que eram destinados à venda e que residiam naquele local juntamente com André. Ambos os guardas ainda ressaltaram que André era pessoa conhecida nos meios policiais pelo seu envolvimento com o tráfico, embora não tenha sido preso em outras ocasiões.

Os depoimentos dos agentes públicos, aliados à confissão do réu, não deixam dúvidas a respeito da mercancia ilícita.

É certo que, se comparados os depoimentos prestados em sede inquisitiva e judicial, sempre será possível verificar a existência de pequenas contradições, que se reputam naturais, porque a ninguém é dado prestar depoimentos estritamente idênticos, sem nenhuma diferença.

O que importa, no entanto, é a coerência no que é fundamental.

No caso, fundamental era a quantidade da droga, sua forma de acondicionamento, com quem foi encontrada e em que circunstâncias isso se deu. Cumpre consignar que nada há nos autos que indique intenção das testemunhas em incriminar indevidamente o acusado.

Além disso, acolher essa tese seria desmerecer o trabalho dos policiais em suas

investigações.

Salvo comprovação em contrário, a atuação dos agentes públicos goza de presunção de veracidade e legitimidade. Sobre o tema, invoco famoso precedente da lavra do eminente Min. Celso de Mello: Prova – Depoimento testemunhal de agentes policiais – Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, 1ª T., HC nº 74.608-0/SP).

De outro lado, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal ou de terceiros, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Acerca da quantidade da substância entorpecente para fins de consumo pessoal, confira-se o seguinte posicionamento doutrinário: Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente. (Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio. Legislação Penal Especial. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 114).

Nessa medida, apreendeu-se significativa quantidade de droga, qual seja, 291 porções de crack, parte em poder do acusado e outra parte no local em que ele estava residindo, acondicionadas de maneira usual para o fornecimento a terceiros. Ademais, há que se considerar que o réu foi detido em local conhecido da polícia como ponto de tráfico de entorpecentes.

Também não há nulidade ou prova ilícita em razão do ingresso no domicílio do acusado sem prévio mando judicial.

O ingresso na residência de qualquer indivíduo, a despeito de sua natureza inviolável, é excepcionado em casos como o dos autos, onde haja a prática de crime e a consequente situação flagrancial, conforme expressamente prevê a Constituição em seu artigo 5º, inciso XI.

Isso porque, o delito de tráfico de entorpecentes possui natureza permanente, cuja ação se protraí no tempo, permitindo a prisão do agente enquanto se mantiver este estado.

Nesse cenário, a garantia fundamental do acusado deve ser flexibilizada em razão de não poder ser utilizada como escudo para a prática de atos ilícitos, em razão da aplicação da técnica de interpretação da cedência recíproca, uma vez colocados em confronto duas garantias de ordem constitucional: a inviolabilidade do domicílio do acusado e a proteção à segurança e saúde públicas, bens jurídicos afetados por sua conduta.

O colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assim decidiu a questão: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o

flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

No caso em apreço, a situação anterior ao ingresso justificou a ação dos agentes públicos, porquanto apreendido o acusado em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, sendo apreendido com ele 8 porções de crack, sendo certo que os agentes relataram que ele próprio indicou que na residência havia mais entorpecentes, de modo a autorizar o ingresso forçado, sem necessidade de entrar no mérito a respeito da autorização do morador, porquanto caracterizada situação de flagrante delito, conforme acima mencionado.

Não há dúvida alguma, então, a respeito da prática do tráfico de entorpecentes, com a incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, pois demonstrado que o acusado envolveu adolescentes para cometimento do crime, uma vez que ambos os guardas relataram que os infantes confirmaram o auxílio ao acusado na prática do tráfico.

Entretanto, considerando a especialidade dessa causa de aumento, não se configura o crime autônomo do artigo 244-B do ECA, conforme sustentado pelo Ministério Público, impondo-se a absolvição.

Nesse sentido: TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Crime cometido com o envolvimento de adolescente. Materialidade e autoria comprovadas. Negativa dos réus infirmadas pelos depoimentos coerentes e seguros dos policiais militares, dando conta da apreensão de uma sacola contendo os entorpecentes com DANIEL, após visualizarem os três acusados e um adolescente agachados e mancomunados para o comércio ilícito. Causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 bem reconhecida. Impossibilidade de absolvição. Condenações mantidas. Delito autônomo do artigo 244-B, do ECA não configurado, diante da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06. Princípio da especialidade. Apelo ministerial postulando, ainda, o aumento das básicas, na primeira fase, em razão da quantidade de entorpecentes, bem como o afastamento, na terceira etapa, do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com relação a FELIPE. Acolhimento parcial. Quantidade razoável de drogas que justifica o aumento das básicas de DANIEL e JANICE, bem como o afastamento do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, quanto a FELIPE, a fim de não configurar bis in idem. 1) FELIPE: Básicas que partiram do piso legal, mantidas nos mesmos patamares, eis que ausentes atenuantes e agravantes, e majoradas de um sexto pela causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06. Afastamento do redutor especial, a pedido do Parquet. 2) DANIEL: Penas-base majoradas em fração única de um quinto acima dos mínimos legais, pela quantidade de drogas e maus antecedentes. Ausentes agravantes e atenuantes. Correto o aumento de um sexto pela referida causa de aumento. 3) JANICE: penas-base

estabelecidas em um sexto acima dos pisos legais pela quantidade de drogas, seguida de majorações de um sexto pela reincidência e de mais um sexto pela causa de aumento. 4) Regime fechado necessário. 5) Apelos defensivos improvidos e recurso ministerial parcialmente acolhido. (TJSP; Apelação Criminal 1502439-87.2019.8.26.0536; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020 - grifei).

Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores (artigos 33, da Lei nº 11.343/06 e artigo 244-B, "caput", da Lei nº 8.069/90), na forma do artigo 69, do Código Penal. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo crime de tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. 2. No caso do crime de tráfico de drogas praticado em concurso com criança e adolescente, tem-se um quadro de concurso aparente de normas, envolvendo a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 e o tipo penal de corrupção de menores, estampado no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, mercê do critério da especialidade, a hipótese enseja a condenação do agente pelo crime de tráfico de drogas, com a aludida majorante, afastando-se o delito de corrupção de menores, sob pena de "bis in idem". 3. Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500057-23.2019.8.26.0213; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guará - 1ª Vara; Data do Julgamento: 05/07/2020; Data de Registro: 05/07/2020 - grifei).

Afasta-se, também, o crime de associação criminosa previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, pois em momento algum foi evidenciado o animus associativo entre o acusado e os adolescentes, relativo à finalidade de praticar, reiteradamente, o crime mencionado no artigo 33, caput, da mesma Lei, tampouco a permanência na *societas criminis*, a qual não se confunde com a mera coautoria.

Acrescento o entendimento dos Tribunais:

O crime consuma-se com a simples associação previamente organizada, de caráter estável e permanente, independentemente de qualquer outro fato que venha a ser cometido pelos agentes. Desde que a associação delituosa, já caracterizada, alcança seu fim consistente na prática de crimes, lesa nova objetividade jurídica, possibilitando o concurso de delitos (STJ, REsp 3.943/SP, 5ª T., rel. Min. Flaquer Scartezini, . 26-9-1990, DJ 5-11-1990, JSTJ 20/45).

O delito previsto no art. 35, da nova lei, pressupõe, para o seu reconhecimento, a demonstração do dolo de associar-se de forma estável. É necessário que se identifique, na *societas criminis*, o caráter permanente, que não se confunde com a mera coautoria (TJMG - Ap. Crim. 1.0145.08.435450-8/001, 5ª Câmara Crim., rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 24/03/2009).

É possível que o acusado tenha cometido tal crime, no entanto, as provas amealhadas aos autos não são suficientes para um decreto condenatório, exatamente porque não comprovado, de forma segura, o caráter estável e permanente do tráfico reiterado entre o réu e os adolescentes, ressaltando-se que se trata de acusado primário e sem outros envolvimento criminais.

Reconhecida em parte a ação criminosa, passo à fixação da pena.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente) e objetiva (motivos, circunstâncias e consequências do crime), com a preponderância do artigo 42 da Lei de Drogas, observo que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes, motivo pelo qual nada há que recomende exasperação, fixando-se a pena-base no patamar legal mínimo, correspondente a 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A quantidade da droga será analisada na terceira fase da dosimetria, para fins de aplicação ou não da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, evitando-se *bis in idem*.

Não há circunstâncias agravantes, e a confissão, ainda que parcial, bem como a menoridade relativa, não podem levar à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Na terceira fase de aplicação da pena, deixo de reconhecer a incidência do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque embora o réu seja primário e não ostente maus antecedentes, está comprovado que se dedicava à atividade criminosa. Como já se observou, com ele foram apreendidas 8 porções de crack e na sua residência foram encontradas mais 283 porções da mesma droga, acondicionados de modo a demonstrar o destino a entrega de terceiros, disseminando-se de forma mais danosa o vício.

Conforme leciona Renato Marcão, a apreensão de expressiva quantidade de droga configura indicativo de que o agente é integrante de organização criminosa. A grande quantidade e variedade da droga, a propósito, atenta com maior intensidade contra o bem jurídico tutelado, porquanto inegável a relevância de seu acentuado potencial lesivo, e faz desaconselhar o reconhecimento do "tráfico privilegiado". (Tóxicos. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 138).

E, no mesmo sentido, confirmam-se os seguintes julgados:

A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas são critérios que evidenciam a dedicação a atividades criminosas, justificando o não reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada (STJ, AgRg no HC 615.796/CE, 5ª T., rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20-10-2020, DJe de 22-10-2020).

Esta Corte tem reiterada orientação de que a quantidade e a natureza da droga, associadas ao contexto em que se deu a sua apreensão, podem evidenciar a dedicação à atividade criminosa (STJ, AgRg no HC 604.754/SP, 6ª T., rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22-9-2020, DJe de 28-9-2020).

Além disso, ficou comprovado que o crime envolveu adolescentes, os quais auxiliavam André na mercancia ilícita, restando isolada a versão dele de que estava há pouco tempo nesta cidade, até porque os guardas municipais mencionaram abordagens anterior em locais conhecidos como ponto de venda de entorpecentes.

Dentro desse contexto, constata-se que não se trata de traficante ocasional, a não merecer o reconhecimento do privilégio.

Ainda nesta fase, considerando a presença da majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, elevo a reprimenda de um sexto, chegando-se a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso mínimo, a qual torno definitiva.

O regime de cumprimento será inicialmente o fechado porque, a despeito do quantum da pena, deve ser considerada a natureza do crime, equiparado a hediondo, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, isto à luz das particularidades do caso concreto.

Não se desconhece que as Cortes Superiores têm permitido a fixação de regime semiaberto ou até mesmo aberto em caso de condenação por tráfico de entorpecentes, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O colendo Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do dispositivo legal que vedava tal substituição, induzindo o Senado Federal a suspender sua execução, mercê da Resolução nº 05/2012.

Desse modo, considerando isoladamente a pena fixada, ter-se-ia como possível a fixação de regime mais brando do que o fechado.

No entanto, as circunstâncias em que o crime foi praticado, observados os fatores de subsidiados pelo art. 59 do CP e 42 da Lei de Drogas, desaconselham a imposição de regime mais brando, observando-se, inclusive, que a grande quantidade de entorpecentes justificou o afastamento do tráfico privilegiado.

De fato, observa-se que o acusado foi surpreendido em ponto conhecido de venda de drogas, mantendo em depósito e guardando cerca de 291 porções de crack, disseminando de forma mais danosa o vício, razão pela qual a concessão dos benefícios pleiteados não faria atender à suficiência quanto à reprovação de sua nefasta conduta, mesmo que não ostente antecedentes.

E colhe-se entendimento do Supremo Tribunal Federal: Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de entorpecentes privilegiado. Pretensão à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inadmissibilidade, diante das condições subjetivas do paciente, devidamente justificadas pelas instâncias ordinárias. Alteração do regime prisional estabelecido. Impossibilidade.

Ordem denegada. 1. Relativamente ao crime de tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), foi recentemente afastada pelo Plenário desta Suprema Corte, no HC nº 97.256 (Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 16/12/10), a vedação contida no art. 44 da Lei de Tóxicos, com declaração incidental de inconstitucionalidade da proibição da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. É possível, contudo, ao magistrado, na apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a manter a pena privativa de liberdade, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados aptos a demonstrar a necessidade da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 44 c/c o art. 59, do Código Penal, não cabendo, na via mandamental, salvo evidente teratologia, a revisão desses fundamentos. 3. A negativa levada a efeito na instância ordinária não apenas atendeu aos requisitos legais, como também respeito o princípio da individualização da pena. 4. Em relação ao regime prisional semiaberto estabelecido para início do cumprimento da reprimenda carcerária, observo que sua fixação está igualmente justificada, diante do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, que impõe a "observância dos critérios previstos no art. 59", segundo o qual o magistrado deve observar a necessidade e a suficiência da sanção "para [a] reprovação e [a] prevenção do crime". 5. Writ denegado (STF, HC 113.134/SC, 1ª T., Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/06/2012).

E, para além das circunstâncias do caso concreto, já delineadas, cumpre observar que, nesta Comarca de Artur Nogueira, vem subindo consideravelmente o número de ocorrências relativas ao tráfico de entorpecentes, seja com maiores de idade, seja com adolescentes, abalando sensivelmente a sociedade, que aguarda resposta estatal mais condizente com as peculiaridades locais.

Por fim, o réu deverá permanecer na prisão, para a garantia da ordem pública, ante a natureza do delito e à vista de todo o exposto, especialmente das considerações quanto à fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente neste momento, com prolação de sentença condenatória, mantidos os demais fundamentos que embasaram a decretação da prisão cautelar.

Ante o exposto (i) condeno André Kayky Ribeiro da Silva, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06; (ii) absolvo André Kayky Ribeiro da Silva, qualificado nos autos, da prática dos crimes previstos nos artigos 35 da Lei nº 11.343/2006 e 244-B da Lei nº 8.069/1990 (ECA), com fundamento, respectivamente, no artigo 386, incisos VII e III, do Código de Processo Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos, em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma dos artigos 61 e 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006.

Fica também autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedida.

O acusado pagará a taxa judiciária, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, em razão de sua hipossuficiência e da gratuidade.

Após o trânsito em julgado: a) Comunique-se o Instituto de Identificação (IIRGD); b) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República de 1988; c) expeça-se guia de execução definitiva ou oficie-se para aditamento da guia de recolhimento provisória, remetendo-se ao juízo competente; d) intime-se o réu para pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias e da taxa judiciária, se o caso, em 60 (sessenta) dias, procedendo-se na forma dos artigos 480 e 480-A das NSCGJ.

Arbitro honorários ao(à) douto(a) advogado(a) dativo(a) no máximo da tabela (Convênio DPE/OAB-SP) – fls. 196/198, expedindo-se certidão.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se e intímem-se.

Artur Nogueira, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA